

Aires, 1960, págs. 14-24; Locke, *op. cit.*, Libro III, capítulo VI, 47, Libro IX, 13-17. Véase también Copi, *op. cit.*, págs. 95 y sigtes.; Hospers, *op. cit.*, págs. 39 y sigtes.; Cohen y Nagel, *op. cit.*, págs. 117-8; Glanville Williams, "Language and the Law", *The Law Quarterly Review*, vol. 61, abril 1945, (págs. 181-95) y julio 1945 (págs. 293-302). Sobre la vaguedad de "hombre" véase Locke, *op. cit.*, Libro III, cap. VI, 27.

15. TEXTURA ABIERTA DEL LENGUAJE (APARTADO III, 4)

Además del trabajo de Waismann citado en el texto, véase Wittgenstein, *Philosophical Investigations*, parágrafo 80: "Yo digo 'Allí hay una silla', ¿Qué pasa si voy hacia ella, con el propósito de tomarla, y súbitamente desaparece de la vista? — 'Así que no era una silla, sino una especie de ilusión'. Pero en escasos momentos la vemos de nuevo y podemos tocarla, etc. — 'Así que después de todo la silla estaba allí y su desaparición fue una especie de ilusión'. — Pero supongamos que después de un tiempo desaparece de nuevo, o da la impresión de que desaparece. ¿Qué habremos de decir ahora? ¿Tenemos reglas listas para tales casos, reglas que digan si podemos usar la palabra 'silla' de manera de incluir este tipo de cosa? ¿Pero es que echamos de menos esas reglas cuando usamos la palabra 'silla'? ¿Y habremos de decir que en realidad no atribuimos ningún significado a esa palabra porque no estamos provistos de reglas para toda aplicación posible de ella?".

Ver también Austin, "The meaning of a word", en *Philosophical Papers*, citado *supra* en nota 6. Ver especialmente págs. 35-37, donde el autor argumenta que el lenguaje ordinario hace crisis ante los casos extraordinarios, dado que no existen convenciones semánticas, explícitas o implícitas, que los incluyan (o excluyan).

El curioso espécimen de apariencia gatuna, que en la pág. 34 del texto habla y muda de dimensiones, está emparentado con el que se echaba una filípica en el citado artículo de Austin y con el que exhibe pasmosa elasticidad en "Verifiability" de Waismann.

SEGUNDA PARTE

SOBRE LA INTERPRETACION EN EL DERECHO

1. LENGUAJE JURÍDICO Y LENGUAJE NATURAL

1. TESIS

Espero que se me conceda sin necesidad de una elaborada demostración que las normas jurídicas, en cuanto autorizan, prohíben o hacen obligatorias ciertas acciones humanas, y en cuanto suministran a los súbditos y a las autoridades pautas de comportamiento, están compuestas por palabras que tienen las características propias de los lenguajes naturales o son definibles en términos de ellas.

(Esa no es una circunstancia meramente accidental; tampoco debe ser vista como un defecto grave ni como una insuficiencia remediable de la técnica de control social que llamamos derecho. El uso eficaz de esta técnica reclama que las reglas jurídicas sean comprendidas por el mayor número posible de hombres. La función social del derecho se vería hoy seriamente comprometida si aquéllas estuvieran formuladas de manera tal que sólo un grupo muy pequeño de iniciados pudiese comprenderlas. Por ello es legítimo decir que las normas jurídicas no sólo se valen del lenguaje natural sino que, en cierto sentido, tienen que hacerlo.)

2. UNA POSIBLE OBJECCION

(Frente a lo que acabo de decir se podría replicar que desde tiempos muy lejanos los juristas vienen elaborando un lenguaje

especializado, compuesto de términos que no forman parte del lenguaje natural, y que esas palabras técnicas, susceptibles de definición precisa, se han incorporado a las leyes y demás normas jurídicas escritas.

Así —continuaría la objeción— cuando el Código Civil argentino usa términos o expresiones tales como "locación", "acto jurídico", "domicilio", "compraventa", "donación", "culpa", "dolo", "derechos reales", "mandato", "nulidad de los actos jurídicos", etc., está valiéndose de palabras o expresiones que tienen altísima precisión. Esto es, de fórmulas verbales cuyos criterios de aplicación son de una nitidez equivalente a la que poseen los criterios de aplicación de palabras o expresiones tales como "esfera", "pentágono", "triángulo isósceles", "tetraedro", etc.

Esa convicción inspira algunos desarrollos hechos por Sebastián Soler en sus libros *Fe en el Derecho*¹ y *La interpretación de la ley*². En el primero se lee que "el comportamiento del derecho guarda relación con las matemáticas" en los dos sentidos: por la forma en que se constituyen los conceptos jurídicos que integran las normas y por la manera en que recíprocamente juegan" (pág. 159). "El contenido del concepto jurídico es, pues, exactamente el que el legislador le ha acordado, y en esto la semejanza entre esta clase de conceptos y los conceptos matemáticos es profunda. Entre el concepto de hipoteca y el de triángulo existe la coincidencia de que ambos están constituidos por un número limitado de elementos puestos" (pág. 162)³.

(En *La interpretación de la ley* Soler repite que "la relación que efectivamente guardan los conceptos jurídicos con los conceptos matemáticos" especialmente con las figuras de la geometría... consiste en que ambos son conceptos dados o puestos por hipótesis, integrados, además, por un número determinado de elementos necesarios") (pág. 42). A continuación da el siguiente ejemplo: "Si hay un acuerdo para transferir el dominio de una cosa mediante un precio, hay compraventa; si suprimimos el precio, hay donación; si en vez de la cosa suponemos un crédito,

¹ *Fe en el Derecho y otros ensayos* (T.E.A., Buenos Aires, 1956).

² *La interpretación de la ley*, Ed. Ariel, Barcelona, 1962.

³ Ver también, *op. cit.*, págs. 165/68, 259/60, 269 y 281/85.

hay cesión; si no hay acuerdo sino engaño, hay estafa. De aquella primera definición no podemos tocar nada, según se ve, sin que la figura se desmorone, como cuando a un triángulo le quitamos un lado" (*op. y loc. cit.*).

Esta equiparación, en el mejor de los casos, es engañosa. Sugiere que las palabras y expresiones jurídicas tienen la misma precisión que las palabras que usa el geómetra para aludir a sus objetos construidos. Si fuera correcta, refutaría mi afirmación de que las normas se valen de un lenguaje que tiene básicamente las mismas características que los lenguajes naturales. Sostengo que no lo es y que la objeción que me ocupa no tiene sino una fuerza aparente. Veamos por qué.

3. CONTRARREPLICA

Es verdad que los juristas se han esforzado por crear un lenguaje en cierto modo artificial, de contornos más precisos, para alcanzar un mayor rigor expositivo. Esa terminología especial se ha incorporado a las normas jurídicas, por lo menos en algunos sectores (p. ej., en el derecho civil). También es verdad que palabras tales como "capacidad", "menor", "heredero", "domicilio", en boca de un jurista y en un contexto jurídico, tienen por lo general mayor precisión que en boca de un lego y en un contexto de lenguaje cotidiano. Es innegable que "donar", como palabra jurídica, tiene contornos más definidos que la palabra coloquial "regalar"; que "pagar", en el lenguaje de los juristas, no significa lo mismo que "pagar" en el habla del hombre de la calle; que "constituto posesorio" no significa absolutamente nada para este último, etcétera.

Podemos conceder todo eso sin dificultad y seguir sosteniendo con firmeza que existen diferencias fundamentales entre el lenguaje de los juristas y un lenguaje formalizado. El primero no es sino una forma menos espontánea y menos imprecisa de lenguaje natural, que muchos juristas usan con la pretensión, consciente o no, de estar usando un lenguaje absolutamente riguroso. No puedo desarrollar aquí este tema con la extensión que merece. Me limitaré a señalar algunas pocas cosas.

a) No es verdad que los términos y los conceptos jurídicos se asemejen a los de la geometría en que unos y otros están integrados por un número determinado de elementos necesarios, que no se pueden tocar sin que la figura (jurídica o geométrica) se desmorone. No es cierto que las llamadas figuras jurídicas poseen "purísimos perfiles indeformables".⁴)

Tomemos, por ejemplo, la palabra "compraventa". No discutimos que para que ella sea aplicable a una cierta transacción tiene que haber precio. Pero, si se me permite el giro, ¿cuánto precio? Porque si la cantidad de dinero prometida o entregada a cambio de una cosa es insignificante en relación con el valor de ésta, los juristas dirán, sin duda, que hay una donación encubierta de la cosa, y no una compraventa. Y si el valor del dinero es desproporcionadamente mayor que el de la cosa, dirán que habido una donación encubierta del dinero, y no una compraventa. ¿Por dónde pasa la línea, si es que hay tal línea, que separa las compraventas genuinas de las donaciones encubiertas? ¿No es más atinado decir que hay aquí una apreciable zona de penumbra, a semejanza de lo que ocurre con "calvo", "joven" y "alto", y a diferencia de lo que acontece con "triángulo" o "cubo" (en el uso que dan a estas palabras quienes hacen geometría pura)?

b) Precisamente porque las palabras jurídicas de cierto nivel están circundadas por una zona de penumbra no son insólitos los casos marginales o dudosos. Los juristas los enfrentan con vacilación; no saben si asignarles un lugar en algunas de las figuras reconocidas que simultáneamente los reclaman y los rechazan, o remitirlos al cajón de sastre de las instituciones atípicas, innominadas o *sui generis*. Nada de esto ocurre en la geometría.)

Los ejemplos pueden multiplicarse. Hay situaciones dudosas entre compraventa y locación de cosas, v. gr.: la llamada venta-*alquiler*, o la venta de frutos o cosechas en pie cuando el comprador toma posesión del inmueble para recolectarlos (Borda, *Contratos*, I, 20/1 y 429; Puig Brutau, *Fundamentos*..., II, 129); entre locación de cosas y depósito, v. gr.: los contratos

⁴ SOLER, *Fe en el Derecho*, pág. 168.

relativos a cajas de seguridad bancarias y de garage (Borda, op. cit., I, pág. 420); entre locación de cosas y sociedad, como ciertas formas de *aparcería* (Borda, op. cit. I, 423); entre locación de servicios, de obra y mandato (Borda, op. cit., II, págs. 9, 16/17, 74/75); etcétera.

¿Cuántas reformas puedo ordenar en el traje de semi-locación que he "comprado" sin que la compra se "transforme" en locación de obra? ¿Y cuántas bastan para poder hablar de "locación de obra"? ¿Hay algún criterio único o alguna suma o disyunción finita de criterios que sean condición necesaria y suficiente para decir que en un caso dado hay "relación de dependencia" y que, por lo tanto, no hay locación de obra sino locación de servicios?

c) La complejidad de las situaciones de hecho desborda las clasificaciones tradicionales. Ello ha impulsado a los juristas a ocuparse, con creciente interés, de problemas como los que se examinan bajo el rótulo de "contratos atípicos" (Ver, Puig Brutau, *Fundamentos*..., II, págs. 393/415 y, entre nosotros, Héctor Masnatta, *El Contrato atípico*, Abeledo-Perrot, 1961).

Por más que los juristas vuelvan su atención a las nuevas estructuras de derechos y deberes que las necesidades cambiantes y el ingenio humano crean día a día, y se afanan por rotularlas (contrato de edición, de exposición, de filmación, contrato deportivo, etc.) y por exponer sus características centrales, aquellas mismas necesidades y esa misma inventiva irán elaborando nuevas estructuras atípicas, frente a las cuales resultará siempre insuficiente el arsenal terminológico y conceptual de los juristas. Y ello es así por las mismas razones que señalé en la primera parte, al destacar por qué la "textura abierta" es una característica irremediable de los lenguajes naturales.)

d) Pero no se piense que sólo en el campo de los contratos ocurren estas cosas. (Aun en los sectores aparentes más formalizados y abstractos nos damos en definitiva con problemas de penumbra, en cuanto intentamos usar las reglas y los conceptos jurídicos para lo que básicamente sirven. Esto es, para guiar la conducta de los hombres de una comunidad y justificar reclamos y decisiones.)

No hace falta mucha agudeza para advertir que, en nuestro sistema, no podemos saber si a un ser humano le es o no aplicable el rótulo jurídico "incapaz" (o "capaz") sin determinar, entre otras cosas, si le son o no aplicables los rótulos "demente" o "sordomudo que no sabe darse a entender por escrito". Y no cabe duda de que estas últimas palabras no tienen, en modo alguno, un campo rigurosamente preciso de aplicación. No hace falta meditar mucho para advertir que si bien la expresión jurídica "domicilio real", equivalente a "asiento principal de la residencia y negocios", tiene ejemplos claros de aplicación, hay numerosos supuestos ante los cuales su aplicabilidad suscita dudas que no pueden resolverse sin tomar una genuina decisión. No es menester gran perspicacia para darse cuenta de que, en nuestro sistema, la expresión altamente técnica "acto jurídico" es o no aplicable a una determinada acción o transacción humana según que ésta pueda o no ser calificada de "acto realizado con discernimiento, intención y libertad", no opuesto a "las buenas costumbres" ni incompatible con "la libertad de la conciencia", expresiones que, huelga decirlo, no acotan una clase de actos perfectamente definida. Lo mismo puede decirse de distinciones tales como las que marcan las palabras "delito" y "cuasidelito", ligadas a "dolo" y "culpa"; o "acto válido" y "acto nulo" (o "anulable"), ligadas a expresiones tales como "error sustancial", "dolo grave, determinante, que ocasiona un daño importante", "injustas amenazas de sufrir un mal inminente y grave", etcétera.

Nadie puede negar que estas fórmulas verbales son claramente aplicables a algunos supuestos de hecho, claramente inaplicables a otros, y dudosamente aplicables a casos atípicos, anómalos o marginales. No podemos encerrarnos en la falsa seguridad de que los tecnicismos del lenguaje jurídico pueden eliminar esta última categoría de casos. La diaria experiencia de los tribunales y, en general, el contacto profesional con el derecho, nos enseñan que esa seguridad es quimérica.

e) Los juristas (no todos) se dan cuenta (no siempre) de estas cosas. Cuando no los obsesiona el afán de alcanzar una inalcanzable seguridad, o el deseo de presentar, con fines didácticos, un cuadro de perfiles nítidos, libre de zonas grises, reconocen que "las categorías jurídicas no presuponen identidad con

las categorías y conceptos de otras ciencias, sino que se inspiran más bien en los conceptos vulgares" (Rotondi, *Istituzioni de Diritto Privato*, pág. 412). Y admiten que por fuerza "tenemos que tropezar con la imprecisión o relatividad de los conceptos jurídicos", pues "existen numerosas zonas de transición, en las que el jurista debe estar alerta para no caer en una peligrosa geometría jurídica" (Dassen-Vera Villalobos, *Manual de Derechos Reales*, Parte General, Tea, 1962, pág. 1).

Los juristas advierten entonces que las clasificaciones jurídicas—incluso algunas tan básicas como la división entre derechos reales y personales—constituyen un "intento de agrupar distintos fenómenos" según caracteres que "no se dan en forma aislada sino en una gran variedad de matices y combinaciones", por lo que "necesariamente debemos contentarnos con criterios aproximativos y flexibles" (Dassen-Vera Villalobos, *ob. cit.*, pág. 4). Y destacan que nociones aparentemente tan precisas como "responsabilidad contractual" y "acción contractual", no son otra cosa que "conceptos clasificadores, cómodos, orientadores y útiles, pero siempre un poco arbitrarios y cuantitativos, como toda tentativa de trazar una línea divisoria allí donde existen matices, gradaciones y zonas de transición" (Gorla, *El contrato*, Ed. Bosch, Barcelona, 1959, pág. 15).

Podemos afirmar, en conclusión, que el lenguaje jurídico tiene básicamente las mismas características que los lenguajes naturales. Señalaré, a continuación, y en forma esquemática, algunas consecuencias que cabe extraer de ello.

II. CASOS TÍPICOS Y CASOS MARGINALES

1. DISTINTOS TIPOS DE CASOS

Las palabras que aparecen en las normas jurídicas para aludir a hechos, sucesos o actividades humanas, y proporcionar pautas o criterios para guiar o juzgar estas últimas, tienen, pues, una zona de penumbra, es decir, son actual o potencialmente vagas. La vaguedad se pone de manifiesto frente al caso marginal o atípico. En su presencia, quien trata de orientar su conducta se-

gún la regla, o apreciar el comportamiento ajeno a la luz de ella, se siente desconcertado. El caso no está claramente incluido en el área de significado central donde se congregan los casos típicos o paradigmáticos, ni claramente excluido de ella.

Por lo tanto, cualquier descripción honesta de lo que ocurre cuando un intérprete (un juez, un funcionario o un particular) trata de determinar si un caso concreto está o no comprendido por el significado actual de una regla, tiene que admitir que no todos los casos son del mismo tipo ni suscitan los mismos problemas. Dicha descripción debe distinguir entre estos dos tipos de casos:

a) aquellos cuyos hechos constitutivos están claramente comprendidos por el área de significado central de los términos o expresiones en que la regla consiste; y
b) aquellos que se encuentran en lo que —siguiendo a Hart¹— hemos llamado zona de penumbra, es decir, que son marginales o atípicos, en cualquiera de las múltiples formas en que esto puede ocurrir.

Esta distinción, a su vez, es vaga, porque depende de la noción de zona de penumbra, que también lo es.

2. DESCUBRIR Y ADJUDICAR UN SENTIDO²

La solución de los casos del primer tipo, que para abreviar llamaré casos claros, puede ser adecuadamente descripta usando

¹ Véase H. L. A. Hart, "El positivismo jurídico y la separación entre el derecho y la moral", en *Derecho y Moral: Contribuciones a su análisis* (traducción de Genaro R. Carrió), Depalma, Buenos Aires, 1962, pág. 24 y sigtes.; y *El Concepto de Derecho* (traducción de Genaro R. Carrió), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1963, Cap. VII, 1. "La textura abierta del derecho". Los desarrollos que seguidamente se hacen en el texto están influidos visiblemente por las enseñanzas de Hart y por el análisis que trae Alf Ross en el capítulo IV de *Sobre el derecho y la justicia* (traducción de Genaro R. Carrió), Eudeba, Buenos Aires, 1963.

² En el uso de esta terminología sigo a Ross y a Perelman. Del primero véase *Sobre el Derecho y la Justicia*, págs. 116/19 y 131 y sigtes. Del segundo, "Avoir un sens et donner un sens", en *Logique et Analyse*, n.º 20, diciembre de 1962, pág. 225 y sigtes.

do expresiones tales como "el intérprete *descubrió* o *halló* el significado que tal o cual norma tiene", o bien "el intérprete aplicó tal o cual regla en su significado objetivo". Pero esa manera de hablar no debe ocultarnos el hecho de que el significado "descubierto" u "objetivo" no puede ser sino una de estas dos cosas: (1) el significado que efectivamente quiso poner en la norma la autoridad que la sancionó; o (2) el significado que en contextos y situaciones semejantes le acuerda hoy el uso lingüístico preponderante, ya sea en la comunidad como un todo, ya en algún sector de ella a cuyos usos lingüísticos se atribuye un carácter privilegiado (por ejemplo, los jueces).

En cambio, la solución de los casos del segundo tipo, es decir, los de la zona de penumbra, no puede ser descripta de ese modo sin engendrar graves equívocos. Estamos frente a un caso atípico, marginal o insólito, en algún aspecto relevante. El caso no está claramente incluido ni claramente excluido por el significado "descubrible" de las palabras de la ley. El intérprete agotado todos los métodos de tipo cognoscitivo y su duda sigue en pie. Ella no deriva de ignorancia de los hechos, sino de ignorancia del significado efectivo de la regla en relación con esos hechos.

Para resolver el problema se ve forzado a *decidir*, bajo su responsabilidad, si esos hechos están o no comprendidos por las expresiones lingüísticas que, a ese respecto, son indeterminadas. Su decisión, en consecuencia, no está controlada por ellas.

Para considerar al caso como incluido o como excluido el intérprete se ve forzado a *adjudicar* a la regla un sentido que, en lo que hace al caso presente, hasta ese momento no tenía. Sólo así puede fundar en ella la inclusión o la exclusión. Ese sentido o significado no estaba en la regla. Claramente ha sido *puesto* por el intérprete sobre la base de una decisión no determinada por los hábitos lingüísticos establecidos. Si esta adjudicación de sentido no es arbitraria (y no tiene por qué serlo), estará guiada por ciertos *standards* valorativos, sociales, políticos, económicos, etc., a la luz de los cuales se aprecian y sopesan las consecuencias de la inclusión o exclusión. Estos criterios adicionales son los que dan fundamento a la decisión; no la regla o reglas del orden jurídico, que simplemente *no se oponen* a ella.

De todo esto se siguen algunas consecuencias cuya enunciación resultará, para muchos, bastante menos monótona que las aparentes trivialidades que recordé en la primera parte, al destacar algunas características de los lenguajes naturales. Esas consecuencias, empero, se siguen *necesariamente* de tales supuestas trivialidades.

3. TRES CONSECUENCIAS

Primera consecuencia: Es falsa la afirmación, tan repetida, de que el derecho, es decir, un cierto orden jurídico, es un sistema cerrado, dotado de "plenitud hermética" o "finitud lógica", del cual pueden derivarse, por deducción, las soluciones para todos los casos posibles. El derecho, o sea un orden jurídico determinado, *tiene lagunas*, en el sentido de que hay casos que no pueden ser resueltos con fundamento exclusivo en sus reglas o en alguna combinación de ellas.

En relación con esto se hacen necesarias, creo, algunas aclaraciones. En primer lugar, cuando afirmo que, en el sentido indicado, todo orden jurídico tiene "lagunas", no quiero decir únicamente que el legislador es incapaz de dar solución anticipada a todos los supuestos, sino algo mucho más radical. A saber, que aun admitiendo que el orden jurídico está integrado también por las pautas jurisprudenciales vigentes, fruto de la labor judicial que va llenando los "vacíos" de la legislación y haciendo frente, con mayor o menor imaginación y coraje, a las cambiantes necesidades del cuerpo social, y aun concediendo que de algún modo no clarificado ese orden se complementa con los conceptos dogmáticos elaborados por los juristas teóricos, siempre quedan y quedarán zonas de indeterminación, cuyos límites son indeterminables. Los casos que se susciten en ellas reclamarán, en su momento, auténticas decisiones (y no simples deducciones). Una vez consolidadas, esas decisiones aportarán certeza a un área que, hasta entonces, carecía de ella. Ese es, precisamente, el papel principal de la jurisprudencia.

En segundo lugar, si al afirmar que un orden jurídico tiene "lagunas", queremos decir todo eso, pero nada más que eso,

entonces no sirve como contra-argumento sostener que no existen "lagunas" porque los jueces no deben dejar de fallar. Tal réplique es insuficiente, aunque se la apoye diciendo que cuando los jueces rechazan una pretensión porque no hay norma positiva que la sustente están aplicando el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, que sería una parte "necesaria" de todos los órdenes jurídicos y que, operando como norma de *clausura*, los presentará como sistemas herméticos, plenos o finitos.

Son varias las razones que hacen que éste no sea un buen contra-argumento. En la mayoría de las ramas del derecho el rechazo de la demanda no es la única alternativa frente a la ausencia de normas expresas que justifiquen claramente su aceptación. (No parece serio, por otra parte, sostener que no hay "lagunas" porque los jueces las colman.) Tampoco lo parece admitir sin análisis que cuando decimos que en ciertos casos los jueces, al rechazar la demanda o al absolver al acusado, *aplican* el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, "aplican" tiene el mismo sentido que cuando decimos que los jueces, al condenar a alguien por homicidio simple, *aplican* el artículo 79 del Código Penal argentino. Pero aunque pudiéramos superar estas dificultades y sostener, sin hacer distinguos, que para todo supuesto hay reglas "aplicables" (las normas positivas o el llamado principio de clausura), siempre cabría preguntarse si podemos deslindar el área cubierta por las primeras y el área "cubierta" por la última mediante un conjunto determinado de criterios precisos que, sin vacilaciones, nos permitan ubicar en uno u otro sector a todos los casos posibles. Porque si no existen tales criterios hay penumbra y, en el sentido en que he usado la palabra, hay "lagunas".

La última aclaración es ésta. De lo expuesto se sigue que no es muy afortunado hablar de "lagunas", pues esta metáfora sugiere la existencia de una clara línea de delimitación entre los casos claros y los que (todavía) no lo son. El uso de una metáfora que posee tal sugerencia puede provocar confusión. Tal vez sea mejor prescindir de ella y decir, simplemente, que el orden jurídico no es un sistema cerrado o finito, sino un "sis-

tema abierto"³, y si esto no suena bien, negar derechamente carácter sistemático al orden jurídico, entendido como un conjunto de reglas usadas por funcionarios y particulares como pautas o criterios de conducta, y no como una estructura coherente de reglas y principios mencionados por teóricos y profesores, a quienes acucia el deseo de presentar, a cualquier precio, una imagen pulcra y nítida.

Segunda consecuencia: Si los jueces no quieren resolver a ciegas o en forma arbitraria los casos de la penumbra (que por razones obvias constituyen una importante proporción de los que se litigan), no les basta con conocer a fondo las normas jurídicas y sus fuentes, ni saber armar con ellas estructuras coherentes.

Tienen que poseer, además, una adecuada información de hecho sobre ciertos aspectos básicos de la vida de la comunidad a que pertenecen, un conocimiento serio de las consecuencias probables de sus decisiones y una inteligencia alerta para clarificar cuestiones valorativas y dar buenas razones en apoyo de las pautas no específicamente jurídicas en que, muchas veces, tienen que buscar fundamento. Algo semejante se requiere de los juristas que no se resignen a ser meros espectadores de un espectáculo que no entienden. De lo contrario ni unos ni otros estarán en condiciones de cumplir una función social verdaderamente útil.

Tercera consecuencia: Es verdad que los casos ubicados en la zona de penumbra tienen título suficiente para atraer, en todo momento, la atención de los juristas profesionales. Pero su aparición siempre constante no es incompatible con el hecho, fácilmente comprobable, de que la aplicación y el uso cotidiano de la mayoría de las reglas que componen un orden jurídico no suscitan, por lo general, problemas semejantes a los que aquellos casos plantean. Importantes sectores de la vida comunitaria están controlados por reglas cuyo significado cubre claramente la enorme mayoría de los supuestos de hecho que están destinadas a regular.

³ Sobre el sistema jurídico como "sistema abierto" ver Levi, *Introducción al razonamiento jurídico* (traducción de Genaro R. Carrió), Eudeba, Buenos Aires, 1964, apartado I, y nota del traductor n.º 3.

Hay que tener en cuenta, además, que existen zonas donde por diversas razones se hace necesaria la intervención de los jueces en la aplicación de las reglas, aunque no haya, ni en el caso quepan, interpretaciones discrepantes. Tal es lo que ocurre, por ejemplo, con la aplicación de las normas penales, de las relativas a divorcio, a trámites sucesorios, a cuestiones que involucren la persona o los bienes de incapaces, etc. En buena parte de estos casos de aplicación de reglas no se requiere que los jueces adopten ninguna actitud crítico-valorativa frente a ellas, ni que escudriñen su finalidad social, ni que se coloquen en una posición análoga a la del legislador. Tales casos pueden estar, en una proporción importante, claramente comprendidos por el significado "natural" de las reglas, que reciben allí una aplicación, por así decir, "automática".

Algo semejante puede llegar a ocurrir en otras áreas del derecho cuando, por razones ligadas a circunstancias económicas especiales, proliferan artificialmente los litigios porque muchos prefieren afrontar un pleito, aun con la certeza de que la resolución final les será adversa, con tal de demorar el cumplimiento de sus obligaciones.

Hablar en todos estos casos de la función "creadora" de los jueces o intérpretes es, sin duda, un abuso de lenguaje y una grave fuente de confusiones, tan grave como hablar de "mera aplicación" en los supuestos de genuina decisión de casos difíciles o dudosos.

III. DOS TIPOS DE UNIFORMIDAD DEFORMANTE

Es equívoco describir la tarea de administración de justicia (o de aplicación de reglas generales a casos concretos) como si todos los casos fueran del tipo de los casos claros o todos del tipo de los casos de la penumbra. El uso de la misma palabra, "interpretación", para aludir a dos actividades básicamente distintas, borra una distinción útil y sugiere una homogeneidad inexistente. Así lo ha demostrado Ross con gran penetración.⁴

⁴ *Sobre el derecho y la justicia*, capítulo IV, págs. 131 y sigs.

Cuando la homogeneidad se alcanza sobre la base de equi-
parar artificialmente todos los casos con los que hemos llama-
do casos claros, se incurre en el vicio de *formalismo* (o racionalismo). Consiste, fundamentalmente, en *no ver* los problemas de la penumbra.

Cuando la homogeneidad se alcanza sobre la base de equi-
parar artificialmente todos los casos con los casos de la penum-
bra, se incurre en el vicio opuesto que, a falta de una denomina-
ción corrientemente aceptada llamaré *realismo extremo*, o más bre-
vemente "realismo". Consiste, fundamentalmente, en *no ver sino*
los problemas de la penumbra.

Se trata de dos exageraciones de signo opuesto que parecen
reclamarse dialécticamente. La segunda surgió como una res-
puesta a la primera y advino a la palestra poseída de un impulso
destructor demolidoramente eficaz. Más adelante veremos que
una y otra exageración, que ejercen una seducción irresistible
sobre el espíritu de los juristas, son tributarias del mismo tipo de
error respecto de ciertas características del lenguaje del derecho
y, en particular, del papel que en la guía de la vida de una co-
munidad desempeñan las normas jurídicas.

1. LA POSICION FORMALISTA

(Tomemos como modelo la variedad de formalismo más ela-
borada y más influyente, por lo menos entre nosotros: la dogmá-
tica jurídica.)

(Sus tesis principales pueden ser resumidas como sigue:

a) El derecho es un sistema cerrado, dotado de plenitud
hermética o finitud lógica, del que pueden derivarse —esto es, de-
ducirse— soluciones para todos los casos individuales, reales o
posibles.

b) No es correcto identificar el sistema jurídico con la vo-
luntad histórica de un legislador o de una sucesión de legislado-
res. La ley, una vez dictada, adquiere una suerte de vida pro-
pia. Su significado no permanece estático sino que evoluciona
con el cambio de los tiempos, siguiendo una línea de desarrollo
que va actualizando sus virtualidades.)

c) (Compete a los juristas —los científicos del derecho—
exhibir y fijar en conceptos los pasos de esa evolución.) A tal
fin, con métodos específicos propios de su disciplina, ellos ope-
ran abstracciones de primer grado: a partir del material en bruto
de las normas positivas arriban a conceptos jurídicos dotados
de nitidez y fijeza absolutas. Esos conceptos jurídicos, a su vez,
pueden servir de base para sucesivas abstracciones de grado su-
perior. El resultado final es un conjunto sistemático y coheren-
te de proposiciones, construidas exclusivamente a partir del ma-
terial positivo dado.

d) (La tarea del juez o del intérprete se reduce a *descubrir*
la regla general que ha de resolver el caso concreto que se le pre-
senta. Esa tarea se alcanza, cuando la complejidad del caso lo
requiere, mediante una integración sistemática, coherente y diná-
mica, de conceptos y figuras jurídicas tomadas de todo el orde-
namiento.) El material está dado exclusivamente por el orden ju-
rídico; no es legítimo echar mano de elementos de otro origen,
a menos que las normas jurídicas expresamente lo admitan. Nada
en la actividad del juez o del intérprete puede describirse como
"creación"; si bien él elabora la regla general bajo la que va a
subsumir el caso, todos los elementos que entran en esa elabora-
ción le están dados o impuestos por el orden jurídico y exclusi-
vamente por él. Todo consiste en saber descubrir la combinación
adecuada.

Espero que esa caracterización, aunque esquemática, no se-
rá considerada una caricatura. Al formularla he tenido princi-
palmente en cuenta el ya citado libro de Soler, *La interpretación*
de la ley, que representa, según mi modo de ver, la más comple-
ta elaboración de la posición dogmática escrita en nuestro idioma.

Esta posición puede ser explicada en función de un con-
junto de factores históricos que permiten entender cómo se lle-
gó a ella. Para comprender por qué se la sigue sosteniendo hoy
se hace menester reparar en ciertas motivaciones de tipo ideoló-
gico. Hay de por medio un explicable anhelo de *seguridad*. (Se
prefiere concebir el derecho como una voluntad impersonal y
objetiva) liberada de las apetencias e intereses de los seres hu-
manos, porque se piensa que esa es la única alternativa frente a

los regímenes caracterizados por las decisiones incontraladas de hombres providenciales. Se trata de optar entre un gobierno de leyes y un gobierno de hombres. Lo primero, que se reputa indudablemente preferible, requiere adherir a las tesis resumidas más arriba. Tal es el planteo.

La variante de formalismo más influyente en nuestro medio es heredera, consciente o no, de la jurisprudencia conceptual (*Begriffsjurisprudenz*) alemana, que mereció primero la adhesión entusiasta y luego el caustico repudio de Ihering. En el mundo anglosajón hubo también una variedad de formalismo, protagonizada por algunos epígonos de Austin que, apartándose del fundador de la *Analytical Jurisprudence*, creyeron que toda la faena de los juristas consiste en la ordenación y sistematización de los conceptos jurídicos de diverso nivel y que la de los jueces se agota en *deducir* soluciones correctas a partir de reglas determinadas.

2. LA REACCION REALISTA

El formalismo desencadenó reacciones a ambos lados del Atlántico. Las hubo moderadas, y también extremas. Entre las primeras debe señalarse la línea sociológica —este rótulo es quizás demasiado impreciso— que en forma directa o indirecta se apoya en el último Ihering, el de *Der Zweck*. Allí se ubica la jurisprudencia de intereses (*Interessenjurisprudenz*), cuyo expositor más brillante es Philipp Heck. Entre las reacciones moderadas se cuenta también la que tuvo como inspirador a Geny. La contrapartida de la *Interessensjurisprudenz* en el mundo de habla inglesa está representada principalmente por Pound y Cardozo.

Entre las reacciones extremas hay que mencionar dos: la *Freirechtslehre*, o concepción del derecho libre, de origen alemán, y su contrapartida en el mundo anglosajón, el llamado realismo jurídico norteamericano de la década 1930/40. Este último movimiento tuvo mucha mayor influencia que su equivalente europeo. Son numerosos los factores que permiten explicar por qué germinó en el suelo de los Estados Unidos y alcan-

zó allí desarrollos tan importantes. No puedo detenerme en eso. (El llamado realismo jurídico escandinavo tiene otro alcance y otras pretensiones, aunque comparte ciertos puntos de vista básicos con el realismo norteamericano.)

(Las críticas al formalismo han seguido, en líneas generales, estas dos direcciones: se le ha reprochado que es *falso* en cuanto descripción de lo que efectivamente acontece en la administración de justicia, y que es *inconveniente* en cuanto modelo de lo que deben hacer los jueces o funcionarios al decidir casos concretos.)

No voy a reproducir aquí esas críticas en detalle. Ellas son bien conocidas. Sólo quiero señalar que (en su afán crítico los "realistas" llegaron a negar que las normas y los conceptos generales desempeñaban un papel importante en la práctica del derecho. Esto es excesivo y su postulación no es necesaria para demostrar las insuficiencias y errores de la posición formalista.

Los "realistas", es verdad, pusieron ante nuestros ojos hechos muy importantes que la teoría jurídica había pretendido ignorar. Pero también es verdad que muchos de ellos confundieron sistemáticamente los problemas psicológicos implicados en la génesis o motivación de las decisiones judiciales y los problemas de un tipo completamente distinto vinculados a la justificación de ellas. Al incurrir en esa confusión echaron por la borda mucho más de lo que era necesario para refutar el esquema formalista.)

Para ello no era menester ponerse la máscara siniestra del Mal Hombre, cuyo punto de vista, dicho sea de paso y mal que nos pese, esclarece mucho de lo que tienen de distintivas ciertas actividades específicas de los abogados. Bastaba con recuperar el punto de vista del Hombre Sensato, para no pasar de una exageración a la opuesta o, en otros términos, para no saltar de un enfoque afectado por una cierta deformación profesional (la de los profesores de derecho) a otro afectado por una deformación profesional distinta (la de los abogados). Los excesos en la crítica condujeron, como suele ocurrir, a un resultado contrario al buscado. Sivieron para robustecer las convicciones formalistas de muchos cultores de la teoría jurídica y para desprestigiar una actitud crítica sana y fecunda.

IV. DOS CRÍTICAS AL FORMALISMO

Ya dije que no voy a reproducir las críticas de los "realistas". En este apartado me limitaré a destacar dos objeciones que los realistas no hicieron por lo menos en la forma en que las expondré. En el apartado siguiente añadiré una tercera, que los "realistas" no pudieron haber hecho porque también los alcanza.

Las dos primeras objeciones apuntan a una de las tesis principales de la dogmática: la que afirma que mediante la síntesis o combinación de conceptos precisos, extraídos exclusivamente del orden jurídico, es siempre posible construir la norma que permitirá, por deducción, fundar la solución del caso y que, por lo tanto, el sistema es cerrado y completo. La tercera objeción apunta a un falso dilema aceptado —expresa o tácitamente— por formalistas y "realistas".

1. PRIMERA CRÍTICA: "UMBRAL" VS "ZONA DE PENUMBRA"

(Se pretende que los conceptos jurídicos que entrarán en la síntesis son fijos y nítidos. Esto es, que carecen de lo que hemos llamado zona de penumbra y que a su respecto solo cabe hablar de "umbral".) Esta última figura de expresión, muy reveladora, pertenece a Soler. En *La interpretación de la ley* este autor señala que la imagen kelseniana del "marco" legal dentro del cual el intérprete crea su decisión puede convenir al caso en que un juez, frente a una estafa, fija la pena en concreto dentro de los límites, mínimo y máximo, autorizados por la ley. Ese elemento cuantitativo, dice Soler, se presta a la imagen del marco, pero si reparamos sólo en el operaremos una especie de escamoteo que ocultará lo más importante de la faena interpretativa. Vale la pena transcribir las palabras de nuestro autor:

"En el caso referido, además de la tarea de escoger entre un mes y seis años, está el de saber, comprender o entender, el significado de 'defraudar' y de 'ardid', porque con respecto a esos elementos de la ley es absolutamente claro que, contrariamente a lo que dicen los neorealistas del tipo de Gray, no es cierto que será *defraudar* y *ardid* lo que los jueces digan efectivamente que lo es... Acaso sea exacto en algunos casos

seguir hablando de un marco, pero nos inclinamos a creer que esos conceptos más bien responden a la idea del sí o del no, están compuestos por un conjunto de notas que se dan o no se dan y, en consecuencia, son o no son. La idea del marco dentro del cual nos movemos libremente no parece convenir en absoluto para definir la actividad desarrollada en este punto por el juez; parece convenir más bien la idea de umbral; lo importante no es lo que haremos una vez que estemos dentro de la casa; lo importante es decidir si entramos o no entramos; estamos frente a un dilema" (op. cit., págs. 73/74).

Soler vuelve sobre el punto un poco más adelante, cuando hace referencia a una distinción entre dos tipos de normas, las que "expresamente crean un marco y las que plantean un dilema en el cual *tertius non datur*" (op. cit., pág. 77). Ya en *Fe en el Derecho* el mismo autor había sostenido que "la fórmula jurídica, reguladora de acciones, se encuentra siempre ante una situación dilemática, que termina en sí o en no, es decir, en la absoluta precisión. En ese plano, *tertius non datur*: podemos o no podemos hacer con derecho"⁵.

Pues bien, esta figura del "umbral", que trata de presentar gráficamente la existencia de una alternativa gobernada por el principio del tercero excluido, es claramente inadecuada. También lo es, dicho sea de paso, la imagen kelseniana del "marco", en cuanto sugiere la existencia de un área de contornos netamente definidos, que separan los supuestos que están dentro y los que están fuera del campo de aplicación de una norma.

La imagen del "umbral" es inadecuada por la siguiente razón. Para que los conceptos y términos jurídicos puedan ser usados para regular una cierta realidad, para autorizar o prescribir acciones humanas, para justificar decisiones acerca de ellas, etc., tales conceptos y términos tienen que ser definibles,

⁵ Op. cit., pág. 130. En el capítulo XIX de ese libro, bajo el título "La solidez ideal del derecho", el autor formula apreciaciones coincidentes. En la pág. 216 se lee que los conceptos jurídicos "tienen cierto alcance, con un mínimo indispensable y una capacidad de absorción que llega hasta cierto punto. Antes de alcanzar ese límite, no hay nada, sobrepasado el máximo, hay otro concepto". Véanse también págs. 245/46; 259/60; 269 y 281/85, todas ellas reveladoras de la posición que criticamos en el texto.

por fuerza, en términos del lenguaje natural. Y ya hemos visto que las palabras del lenguaje natural no tienen criterios de aplicación rígidos o de perfiles nítidos. *Todas* ellas son actual o potencialmente vagas. No es verdad que su aplicación plantee necesariamente un dilema en el cual *tertius non datur*. El principio del tercero excluido sólo vale para símbolos no interpretados; esto es, en dominios donde —como ocurre en matemática pura o en lógica— se opera con símbolos precisos.

Las afirmaciones de Soler, o bien presuponen que un sistema jurídico está constituido a semejanza de un sistema de geometría pura —y esta presuposición abre un flanco difícilmente defendible frente a las críticas de los “realistas”— o no se hacen cargo de ciertas características de los lenguajes naturales que desde hace algún tiempo se vienen destacando con insistencia.

A la imagen del “umbral”, a la concepción de que el lenguaje de los juristas está integrado por palabras “que responden a la idea del sí o del no”, a la afirmación de que tales términos se refieren “a un conjunto de notas que se dan o no se dan”, y en consecuencia, “son o no son”, de suerte que su aplicación nos coloca “frente a un dilema ante el cual *tertius non datur*”, cabe responder con estas palabras de Bertrand Russell⁶:

“Consideremos las diversas formas en que las palabras comunes son vagas, y comencemos con una palabra como ‘rojo’. Es perfectamente evidente, desde que los colores constituyen un continuo, que hay matices de color que dudaremos en llamar o no rojos, no porque ignoremos el significado de la palabra ‘rojo’ sino porque es una palabra cuyo campo de aplicación es esencialmente dudoso. Esta es por cierto, la respuesta al viejo acertijo del hombre que se volvió calvo. Se supone que al principio no era calvo, que perdió sus cabellos uno por uno y que sólo entonces quedó calvo; por lo tanto, se arguye, debe haber habido un cabello cuya pérdida lo convirtió en un hombre calvo. Esto, por supuesto, es absurdo. El de ‘calvicie’ es un concepto vago; algunos hombres son efectivamente calvos, algunos no lo son, mientras que entre ellos hay

⁶ “Vagueness”, *The Australasian Journal of Psychology and Philosophy*, t. 1, pág. 84, año 1923; artículo traducido al castellano bajo el título de “Vaguedad”, y publicado en *Antología Semántica*, compilada por Mario Bunge, Nueva Visión, Buenos Aires, 1960, págs. 14/24.

hombres de quienes no es verdadero afirmar que deben ser calvos o no. La ley del tercero excluido es verdadera cuando se emplean símbolos precisos, pero no es verdadera cuando los símbolos son vagos, como lo son de hecho todos los símbolos. Todas las palabras que describen cualidades sensibles tienen la misma clase de vaguedad que la palabra ‘rojo’... El hecho es que todas las palabras son sin duda atribuibles en cierto dominio, pero se tornan cuestionables dentro de una penumbra, fuera de la cual son sin duda no atribuibles. Alguien podría tratar de obtener precisión en el uso de las palabras, diciendo que ninguna palabra puede ser aplicada en la zona de penumbra; pero por fortuna la penumbra misma no es exactamente definible; y toda la vaguedad que confiere al uso primario, la confiere también cuando tratamos de fijar un límite a su indudable aplicabilidad”. (Las bastardillas son mías).

Esta cita resulta tan oportuna que no he podido resistir a insertarla, pese a su extensión. Porque no puede caber duda de que “ardid” o “defraudar” son palabras que acotan cierto campo de la realidad —en este caso, del comportamiento humano— con una vaguedad o imprecisión por lo menos igual, si no mayor, que la que exhiben los ejemplos utilizados por Russell.

2. SEGUNDA CRÍTICA: EL CARACTER INFINITO DE LAS COMBINACIONES POSIBLES Y LA REGLA O REGLAS DE SELECCION

La segunda crítica nos llevará menos tiempo. Puede ser formulada así:

El número de síntesis o combinaciones posibles es infinita. Así lo hace notar Soler en *La interpretación de la ley*. Véase, por ejemplo, la comparación con el alfabeto (pág. 161) y especialmente las págs. 165/66, donde dice: “Las combinaciones en que cada letra puede entrar son infinitas y con suma frecuencia, sobre todo en ciertos idiomas, la función cumplida por la letra es muy diferente, según sea el lugar que ocupa en las palabras, y según sean las vecinas entre las cuales se encuentre... *Semientemente ocurre en el derecho*. La función cumplida por un precepto varía intensamente según el complejo en que se inserte” (Las bastardillas son mías).

Pues bien, si la elección de *una* de esa infinita serie de combinaciones o síntesis posibles no se efectúa al azar (y asumo que nadie pretenderá que así ocurren las cosas ni, mucho menos, que así deben ocurrir), entonces ella estará guiada por algún principio o criterio de selección y síntesis. Si se piensa que ese criterio selectivo es externo al sistema —ciertos juicios de valor fundados en consideraciones políticas, económicas, etc.— ello importa admitir que el mismo *no es completo*. Pero aunque se considere que es interno al mismo, como parte de sus reglas de decisión (algo así como reglas de segundo grado que prescribirían la forma de realizar las síntesis para cada caso), tales reglas de segundo grado tendrían por necesidad —salvo que fuesen vacuas— su *propia* penumbra de vaguedad o textura abierta, y así hasta el infinito.

No es posible remediar la indeterminación que surge de la textura abierta, porque las reglas destinadas a ello llevarían consigo su *propia* halo de penumbra. Recuérdese la parte final de la cita de Russell: “la penumbra misma no es exactamente definible; y toda la vaguedad que confiere al uso primario la confiere también cuando tratamos de fijar un límite a su indudable aplicabilidad”. La indeterminación marginal del orden jurídico es algo con lo que tenemos que contar; no puede ser eliminada con esperanzas ilusorias, por muy dignos que sean los motivos que las inspiran. La certidumbre absoluta en estas cuestiones es algo que falta, como tantas otras cosas, en el limitado equipaje de los hombres.

V. UNA CRÍTICA A FORMALISTAS Y “REALISTAS”

Hay una tercera objeción básica que también apunta a un olvido de ciertas características de los lenguajes naturales, evidenciado en la aceptación dogmática de un falso dilema. Esta objeción alcanza por igual a formalistas y “realistas”. Unos y otros presuponen sin análisis la verdad de esta alternativa: o las normas determinan la totalidad de la conducta o no hay normas sino puras decisiones individuales. El formalista, que tiene explicable horror ante la inseguridad, se decide por el pri-

mer término. El “realista”, que sabe que la seguridad absoluta no es bien deparado a los mortales y que está persuadido, por ello, de que las normas jurídicas no pueden proporcionarlo, se decide por el segundo término.

Para un ejemplo claro de la aceptación del falso dilema por un pensador de cuño formalista puede verse el ya citado libro *La interpretación de la ley*, de Soler. Criticando a Recasens Siches, expresa dicho autor:

“No entendemos, por ejemplo, cómo puede reconocerse que el derecho debe ‘elaborar conceptos abstractos’ pero no tomarlos como ‘mandatos inflexibles’. La cuestión consiste en saber —según lo veremos más adelante— si puede haber normas en general sin que ellas estén constituidas necesariamente por abstracciones, cuestión a la que no parece que pueda darse más que respuesta afirmativa. Si esa es una necesidad de toda norma, está sobrando la referencia a los mandatos *inflexibles*. O ponemos las normas mediante abstracciones porque no hay otra manera de ponerlas, o no las ponemos; pero parece un poco juguetón el pensamiento que después de reconocer el primer término del dilema se complace en acartar la esperanza de que pongamos las normas para no cumplirlas, o bien, al menos para que sean siempre flexibles, aun cuando las hayamos querido poner como inflexibles”⁷.

La idea de que los “realistas” pagan tributo, paradójicamente, al mismo error, está expuesta por Dickinson⁸ y por Hart. Dice este último: “El escéptico ante las reglas es a veces un abso-

⁷ *Op. cit.*, págs. 35/36. Para otros ejemplos de la aceptación expresa o tácita del falso dilema ver *op. cit.*, págs. 3, 44, 127, 128, 132, 137-38, etc.

⁸ “Legal Rules. Their Function in the Process of Decision”, 79 *University of Pennsylvania Law Review*, 833, pág. 835, y “Legal Rules. Their Application and Elaboration”, en 79 *University of Pennsylvania Law Review*, pág. 1059.

⁹ *El concepto de Derecho*, págs. 173/74.

sobre lo que es la existencia de una regla puede consistir en un ideal inalcanzable, y cuando descubre que lo que llamamos reglas no realiza ese ideal, expresa su desilusión negando que haya o que pueda haber regla alguna".

La buena tesis consiste en rechazar por inaceptable el dilema. Ese rechazo halla fundamento seguro en un buen análisis de las características del lenguaje. Hay normas jurídicas y ellas desempeñan un papel indispensable en la práctica cotidiana del derecho. Pero esas normas no determinan toda la conducta pues tienen una textura abierta o presentan una zona de penumbra, dentro de la cual el intérprete tiene que decidir bajo su responsabilidad. Tal decisión no puede ser razonablemente descrita como una simple deducción a partir de reglas que ya tenían un significado que aquél se limitó a descubrir. En otros términos, las reglas del sistema controlan los casos claros, pero no los de la penumbra. Y en eso exhiben las mismas características que el lenguaje natural.

NOTAS Y COMENTARIOS

1. LENGUAJE JURIDICO Y LENGUAJE NATURAL (APARTADO 1)

"El lenguaje ordinario, en el que el derecho está necesariamente expresado —porque, de otro modo, ¿cómo podría preservarse su contacto con la vida real?— no es un instrumento de precisión matemática, sino que presenta lo que con acierto ha sido llamado una "textura abierta" (Dennis Lloyd, *Introduction to Jurisprudence*, Stevens & Sons, Londres, 1959, pág. 398).

En *Fe en el Derecho y otros ensayos*, T.E.A., Buenos Aires, 1956 (págs. 129-130), Soler expresa que "el primer objeto de las normas consiste en que las gentes las entiendan, sin distinciones sociales y a pesar de los grandes desníveis que existen dentro de una misma comunidad". A diferencia de la doctrina jurídica, que "puede... presentarse con un mayor o menor grado de hermetismo defensivo de su exactitud", la norma, "término y fin de toda teoría jurídica, es decir, el verdadero derecho, no tiene más remedio que sumergirse en el mundo de las palabras: debe recoger y emplear esos modos expresivos que la vida cotidiana crea, deforma, amplía y corrompe, porque aspira a regir la conducta de todos. Su primera necesidad es la de ser entendida, para que pueda ser obedecida". Soler cree, sin embargo, que con ese material es posible —aún más, es necesario— acuñar fórmulas verbales rigurosas, dotadas de absoluta precisión: "La exactitud tajante de las palabras de la ley es una exigencia de la necesaria exactitud de sus disposiciones, no ya en (sic) una mera complacencia estética. La ley debe a un tiempo